

1500784-48.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500784-48.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500784-48.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2209486/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 26509498 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2209486 - DEL.POL.VARGEM

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JUESSY MULLER DE ALMEIDA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

ANDRÉIA APARECIDA BALDISSERA DE PAULA e JUESSY MULLERDE ALMEIDA SILVA foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, c.c. o artigo 40, inciso V, e do artigo 35, todos da Lei 11.343/2006, porque, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 17h15min, na Rodovia BR 381, km 10, no Município de Vargem e Comarca de

Bragança Paulista, agindo em concurso, transportavam e traziam consigo entre Estados da Federação, para fornecimento ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, 105 (cento e cinco) grandes tabletes de maconha, droga/entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

ANDRÉIA APARECIDA BALDISSERA DE PAULA também foi denunciada como incurso no artigo 34, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro, pois dirigiu o veículo automotor Hyundai/I30, placa LLI- 8G26, em alta velocidade, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia.

Devidamente notificados, os acusados apresentaram defesa preliminar às fls. 248/251 e 252/255. Recebida a denúncia aos 13 de setembro de 2022 (fl. 260/261), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação, ao final, promoveram-se os interrogatórios dos acusados (fl. 304).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 308/315).

A defesa pugnou pelas absolvições embasadas na inexistência de provas das autorias e na fragilidade dos depoimentos colhidos. Com relação à acusada Andreia, postulou o reconhecimento do erro de tipo. No que toca à dosimetria, combateu a causa de aumento de pena denunciada (fls. 318/337).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico está plenamente comprovada.

Os laudos de exame químico-toxicológico (fls. 185/188) descreveram e concluíram que a substância analisada é maconha, caracterizada por meio de análises químicas e cromatográficas.

Pelos testemunhos colhidos as autorias também se evidenciaram.

O acusado Juessy confessou a prática delitiva e, como sói costuma acontecer, tentou eximir Andréia da imputação criminal. Narrou que foi convidado para levar as drogas para o Município de Vargem. Informou que o contratante lhe emprestou o carro, que teria sido retirado em um supermercado em Jacareí. Como não tinha CNH, solicitou à Andréia para que ela conduzisse o veículo, mas ela não sabia das drogas que estavam sendo transportadas no porta malas. Informou que, no passado, manteve um relacionamento amoroso com Andreia. Disse que o interior do veículo estava com odor de maconha porque é usuário e fumou no trajeto. Esclareceu que Andréia, na condução do veículo, somente empreendeu fuga quando foram abordados pela polícia rodoviária porque lhe pediu que assim agisse. Confirmou que já foi processado pelo delito de tráfico de drogas.

Andréia negou a ciência sobre a traficância. Informou que Juessy passou em sua casa pedindo para que ela o levasse ao Município de Vargem, pois não era condutor habilitado. Disse que aceitou ajudá-lo. Narrou que Juessy passou na sua residência com o veículo e assumiu a direção. Ao ser indagada sobre a procedência ou documentação do veículo, disse que não desconfiou de irregularidades, pois o veículo era relativamente novo. Questionada sobre o cheiro de maconha dentro do veículo, disse que não desconfiou, pois Juessy era usuário, fumou no veículo e acreditava que o odor de maconha tivesse sido devido ao consumo. Sobre a condução do veículo, narrou que conduziu o auto na velocidade permitida na via. Disse que, ao serem abordados pela polícia, ela encostou o veículo, porém Juessy começou a gritar para que ela não parasse, pois ele estaria com problemas. No final, foram abordados pela polícia e só viu as drogas na delegacia. Confirmou que já foi processada outras vezes.

Suas escusas não convenceram e restaram isoladas, assim como a versão de Juessy no sentido de que Andréia nada sabia quanto à droga.

Gize-se, inicialmente, que durante seus interrogatórios policiais ambos os acusados se calaram.

“Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo”.

Ora, se de fato Juessy fosse o único proprietário da droga, certamente Andréia teria declarado tal situação durante seu interrogatório extrajudicial, assim como Juessy também teria assumido. Somente em Juízo eles apresentaram tais versões.

Por outro lado, informalmente aos Policiais, os acusados disseram que estavam transportando a droga de São Paulo para Extrema – MG, e que iriam receber quatrocentos reais por cada quilo de droga transportada.

No mais, deve-se frisar que durante a diligência policial foi apreendida uma grande quantidade de droga, aproximadamente 105 (cento e cinco) grandes tabletes de maconha.

Destarte, a circunstância dos acusados estarem na posse dessa quantidade de maconha, configura, por si só, a plena demonstração do animus de traficar, mesmo porque, nenhuma prova favorável existe nos autos que demonstre a exclusiva propriedade por Juessy. Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

A par disto, não é crível que Andreia aceitasse transportar Juessy em carro de desconhecido, sem que tivesse verificado a documentação, sem saber o destino certo do colega de empreitada, sem ao menos desconfiar da ilicitude da conduta. Sua versão é mendaz.

No mais, eles se escusaram da imputação através de simples negatória geral, sem indicar por quais motivos poderiam os policiais lhes imputar injustificadamente tal crime.

Se não bastasse a força de convencimento insita nos argumentos expostos, corroboram a certeza das autorias os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas ouvidas durante a instrução.

Senão vejamos.

O Policial Rodoviário Frank informou que, durante patrulhamento de rotina, visualizou o veículo ocupado pelos acusados trafegando em alta velocidade. Então solicitou que a condutora do automóvel encostasse mais a frente. Ao chegarem próximos, perceberam o odor de maconha, mas antes de abordarem os réus, a condutora do veículo empreendeu fuga. Após perseguição, logrou deter os acusados. Narrou que ambos os ocupantes desembarcaram, após a ordem da polícia, sendo que o homem ficou no local e a mulher tentou fugir correndo a pé. Entretanto, foi capturada. Dentro do veículo foram localizadas as drogas. Acrescentou que ambos confirmaram que estavam realizando o transporte dos entorpecentes de São Paulo até Minas Gerais, pois receberiam quatrocentos reais pela quantidade transportada.

Eis suas palavras:

J.: Nós estamos tratando de uma acusação de tráfico de entorpecentes, contra a dona Andréia Aparecida e seu Juessy Muller. Fatos que aconteceram dia 02 de agosto desse ano, aqui no município de Vargem. Como é que foi essa diligência? O senhor pode nos contar?

D.: Estava em fiscalização de rotina quando vi um veículo se aproximando em alta velocidade, mandamos encostar. Ao chegar próximo ao veículo a gente percebeu que tinha um forte odor característico de maconha né? Então a gente pediu pra ele encostar um pouco mais pra frente, devido à segurança ali da via, pra gente fazer a fiscalização. Nesse momento então, o veículo empreendeu fuga da equipe. Aí entramos na viatura né, começamos o acompanhamento. O veículo foi fazendo diversas ultrapassagens perigosas, andando na contramão, em fuga da equipe, até que chegou num ponto que o trânsito estava impedido, então não conseguindo mais prosseguir com o veículo. Os dois ocupantes desembarcaram, após a ordem da polícia, sendo que o masculino ficou no local e a feminina se evadiu do local correndo a pé. Até que a gente conseguiu capturar os dois. É, logo depois né? Indagados sobre os nomes dos mesmos, o masculino indicou que o documento dele estava dentro do veículo, e depois a gente averiguou ser documento falso né? E no interior do veículo tinha 105, se eu me lembro bem, era 105 tabletes de substância análoga à maconha.

J.: Sobre o entorpecente eles falaram alguma coisa?

D.: Ah! Alegaram que estavam transportando o entorpecente e que ia ganhar cerca de quatrocentos reais por quilo. Se eu não me engano, um valor próximo a isso.

Suas palavras são confirmadas pelo Policial Rodoviário Lucas, que de forma séria e coerente narrou a abordagem realizada aos acusados, bem como a fuga que levou à abordagem. Certificou o encontro das drogas no veículo, bem como a admissão informal de ambos no sentido que estavam levando as substâncias entorpecentes até a cidade de Extrema-MG.

Como se percebe o delito de tráfico de entorpecentes, restou devidamente configurado.

A alegação de erro de tipo invocada pela defesa de Andréia, não prospera, conforme ficou consignado. Não há elementos probatórios que indiquem que a acusada não sabia da ilicitude do transporte. Não houve justificativa plausível para a reação sintomática consistente na fuga da acusada. Se de boa fé, deveria ter parado quando instada pelas autoridades policiais e declinado que as drogas pertenceriam apenas ao acusado. As condições espúrias da localização dos agentes, a condução do veículo em alta velocidade, a ausência de documentação, a fuga na condução e, posteriormente, a pé da acusada, afastam as ilações da defesa. Neste sentido:

“Apelação – Recurso da defesa – Tráfico de drogas – Erro de tipo – Alegação de não conhecimento da existência de 256 tijolos de maconha na carga transportada pelo recorrente – Afastamento – Elementos probatórios no sentido imediata percepção do odor exalado pela droga transportada – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Validade e coerência dos depoimentos dos policiais – Destinação das drogas à entrega ao consumo de terceiros – Circunstâncias do fato assim reveladoras – Penas – Bases elevadas de um sexto ante a quantidade de entorpecente – Quantum que até

beneficiou o apelante, mas não pode ser alterado em recurso exclusivo da defesa - Reincidência específica - Correto agravamento de um terço - Impugnação à agravante relativa ao estado de calamidade - Impossibilidade de conhecimento do apelo nesta parte porque não aplicada pela r. sentença - Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Correto afastamento - Réu dedicado à prática de atividades criminosas - Circunstâncias impeditivas da incidência do redutor - Erro material no cálculo da multa - Retificação em benefício do réu operada de ofício - Regime inicial fechado - Adequação - Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida, retificado, de ofício, erro material no cálculo da multa." (TJSP; Apelação Criminal 1515444-96.2020.8.26.0228; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirapozinho - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/09/2021; Data de Registro: 08/09/2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVA ORAL INCRIMINADORA - DESCABIMENTO DA TESE DE ERRO DE TIPO - PROVAS QUE DENOTAM TER O RÉU PROMOVIDO O TRANSPORTE CONSCIENTE DA DROGA APREENDIDA NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR DO CÁLCULO PENAL CONSIDERAÇÕES SOBRE REGISTROS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO, A TEOR DO VERBETE SUMULAR Nº 444 DO STJ - REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE." (TJSP; Apelação Criminal 1503580-32.2018.8.26.0228; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019)

Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pela prisão dos acusados tivessem qualquer motivo para imputar a eles, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comercial fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade dos agentes. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado, responsáveis pela repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial. Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna

jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrim/SP - JUTACRIM 30/221).

Repise-se, assim, que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e uníssonos. Frise-se também que ambos agentes públicos em seus depoimentos esclareceram, sem nenhuma contradição entre eles, o ocorrido naquela ocasião, inclusive com riquezas de detalhes demonstrando toda a operação realizada desde a chegada ao local, a abordagem policial e revista aos agentes, não havendo, em princípio, nada que desabone esses depoimentos.

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROCESSO PENAL - PROVA -DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - IDONEIDADE -RECONHECIMENTO. É idônea a prova testemunhai colhida, constituída do depoimento dos policiais que efetuaram a diligência. (TJ-SP - APL: 993061147033 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/05/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2010)

APELAÇÃO. INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito têm natureza de "crimes permanentes", admite-se a prisão em flagrante sempre, ainda que esta prisão seja realizada no interior de uma residência. Precedentes do STF. 2. As autorias e as materialidades dos crimes de tráfico de drogas e roubos, um majorado e outro simples, restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na casa do réu e os objetos roubados encontrados em sua posse. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 12. O instituto da detração, para ser aplicado, depende da análise da situação processual do sentenciado, inclusive no que concerne a eventuais condenações e unificação de penas. Portanto, o Juízo das Execuções Penais é a sede mais adequada para a apreciação da matéria. 13. Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00628017920128260050 SP 0062801-79.2012.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática, reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo correto. 4. Mantém-se o regime inicial de

cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, "in casu", o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014)

Não foram ouvidas testemunhas de defesa.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, o local e as circunstâncias como foram surpreendidos, tudo indica para um transporte para a finalidade venda de drogas.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenham os agentes efetuado a venda. Basta que a possuam ou tenham em depósito com o fim de colocá-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclituação do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

A propósito, os ensinamentos do ilustre doutrinador MENA BARRETO, que bem demonstram o entendimento pacífico sobre a matéria:

"Afinal, cabe nesta oportunidade lembrar, igualmente, algumas ações delituosas que têm caráter formal ou de consumação antecipada e que por via de consequência, dada a sua não-fragmentação, desautorizam a aceitação de tentativa. É o caso, verbi gratia, das relativas à guarda, ao depósito ou ao transporte de tóxicos, além da simples posse (trazer consigo)" (Lei de Tóxicos, Comentários por Artigo. Freitas Bastos, 1996, p. 74.).

A conduta praticada pelos acusados amolda-se perfeitamente às figuras "guardar, ter em depósito e transportar", previstas no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, bem comprovadas as autorias e materialidade da infração, ficando sem guarida as combativas alegações das defesas.

Não obstante os argumentos já expendidos em relação ao crime de tráfico, não deve prosperar a imputação de associação para tal finalidade.

Isto porque os acusados nada admitiram neste particular. Nenhum vestígio existe a respeito de uma eventual associação duradoura e estável entre eles. Os policiais nada relataram sobre a associação imputada.

O crime de associação se distingue do concurso eventual de pessoas que exige um acordo de vontades ocasional e efêmero para a perpetração de determinado crime; a associação pressupõe ajuste permanente ou estável para a perpetração de vários crimes de tráfico de entorpecentes (mínimo dois).

A propósito, dispõe o artigo 35: Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput"e § 1.º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Com efeito, são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a" reiteração ou não "jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33 e 34 da lei nº 11.343/2006, com dolo específico ou elemento subjetivo do tipo, não havendo necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos de sua definição.

Neste sentido preleciona Vicente Greco Filho:

"Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..."(GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção - Repressão: Comentários à Lei n.º 10.409/2002 e à parte em vigor da Lei 6368/76 - 12.^a ed. Atual. - São Paulo - Editora Saraiva - 2006 - p. 127).

Portanto, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris* em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico.

Na espécie, repise-se, inexistem elementos sólidos a embasar o édito condenatório, não havendo como reconhecer, *in casu*, o delito de associação.

Restando, pois, sem comprovação o animus associativo mais ou menos estável ou permanente, não há que se falar em associação para o tráfico, pois, para a sua caracterização é indispensável à associação de duas ou mais pessoas; acordo dos parceiros; vínculo associativo; e a finalidade de traficar tóxicos, formando uma verdadeira *societas sceleris* para essa finalidade.

Não se vislumbrou a ocorrência de outros crimes de tráfico, como ainda, uma estabilidade na relação entre os acusados, razão pela qual suas absolvições se

impõem.

Por fim, inviável qualquer apreciação sobre eventual violação ao dever de cuidado insculpido no artigo 34, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro, ante a atipicidade da conduta, tratando-se de mera infração administrativa.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade das condutas praticadas pelos condenados não justifica aumento nas penas-base. Os acusados ostentam maus antecedentes (fls. 83/87 e 95/98), assim as penas bases são novamente exasperadas.

Os motivos e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, estes fatos de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena.

No entanto, levando em consideração as circunstâncias do crime, a par da quantidade da droga apreendida, em obediência ao teor do artigo 42, da Lei 11.343/2006, vemos que as penas-base comportam acréscimo por conta deste fator.

Presentes as circunstâncias judiciais acima expostas, que devem levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 7 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias multa para ambos os acusados.

Na segunda etapa, presente a reincidência dos condenados - Juessy (autos de n. 0004792-38.2016.8.26.0292 - fls. 84) e Andréia (autos de n. 0000874-84.2017.8.26.0617 - fls. 95). Destarte, as penas são aumentadas em 1/6 perfazendo 08 (oito) anos e 02 (dois) meses, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Deixo de considerar a confissão de Juessy, porquanto parcial, prestada apenas com o fito de ensejar a absolvição da parceira de crime, não contribuindo, assim, com a verdade real. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Preliminar de ilicitude das provas obtidas mediante realização de busca pessoal sem fundadas suspeitas - Procedimento realizado obedecendo os ditames legais - Afastamento - Materialidade e autoria comprovadas nos autos - Prova cabal a demonstrar que o réu trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida - Penas bem fixadas - Confissão parcial do agente que não pode ser considerada para reduzir a reprimenda imposta - Penas bem dosadas - Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da dedicação do réu às atividades criminosas - Réu reincidente - Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos - Regime prisional inicial fechado compatível com a gravidade do crime, com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da suficiência da pena. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1502457-43.2021.8.26.0535; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2022; Data de Registro: 24/10/2022)

Na etapa final a causa especial de aumento denunciada deve incidir.

É certo que os condenados transportavam a droga entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, caracterizando o tráfico entre tais unidades da federação. Assim indicam os depoimentos existentes que comprovam que eles estavam seguindo rumo ao Estado de Minas Gerais. Logo, as penas serão acrescidas de 1/6 totalizando 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-

multa.

Os acusados são reincidentes, razão pela qual não fazem jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

O crime de tráfico foi equiparado, legalmente, aos hediondos, motivo pelo qual os condenados não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade, mesmo porque a reincidência impede a substituição. Também compartilho do entendimento de que o crime de tráfico de drogas é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias envolvidas, de modo que a concessão de regime menos gravoso ou mesmo de qualquer outro benefício, como a substituição da pena ou mesmo do sursis, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou mesmo reprovação da prática delitiva, gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, do Código Penal, além de verdadeira sensação de impunidade.

Por conta dos mesmos fundamentos os condenados deverão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois é o que melhor se amolda para início do cumprimento da pena por crime tão grave e atroz contra a saúde pública. Qualquer outro regime prisional não se coaduna com o tráfico, diante de tantas mazelas que sabidamente a droga provoca.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:
Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

Os sentenciados não poderão apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de:

a) CONDENAR ANDRÉIA APARECIDA BALDISSERA DE PAULA como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c artigo c.c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11343/2006, à

pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica; ABSOLVÊ-LA da imputação do artigo 35, "caput", da Lei 11.343/2006, que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal e ABSOLVÊ-LA da imputação artigo 34, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro, que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código Processual Penal.

a) CONDENAR JUESSY MULLER DE ALMEIDA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c artigo c.c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica; e ABSOLVÊ-LO da imputação do artigo 35, "caput", da Lei 11.343/2006, que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal.

Recomendem-se nas prisões onde estiverem.

Concedo a eles os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 11 de novembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA